

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 06-11-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processos: TC-021323.989.24-4
TC-021458.989.24-3

Representantes: Jonas de Oliveira Melo Silveira
Marcela Furlan Baggio

Representada: Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste.

Assunto: Exame prévio de edital do Pregão Eletrônico nº 22/2024, do tipo menor preço global, que tem por objeto a *“prestação de serviços de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco), em locais onde o DAE executou obras, ligações de água e esgoto, manutenção em redes de água e esgoto, bem como demais locais danificados pelo DAE e de demandas futuras, com fornecimento de veículos, equipamentos e insumos necessários para a manutenção das vias urbanas”*.

Responsável: Laerson Andia Junior (Diretor Superintendente)

Subscritores do edital: Laerson Andia Junior (Diretor Superintendente) e Sonia Regina Franco de Freitas Rosalen (Diretora de Gestão Institucional, Serviços e Deslocamento).

Advogados cadastrados no e-TCESP: Jonas de Oliveira Melo Silveira (OAB/SP nº 144.416), Palamede de Jesus Consalter Junior (OAB/SP nº 275.263), Marcela Furlan Baggio (OAB/SP nº 367.979).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO). PREVISÃO DE BENEFÍCIOS À ME E EPP. LEI FEDERAL 14.133/21. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO LOTE ULTRAPASSA O LIMITE DE ENQUADRAMENTO. HABILITAÇÃO TÉCNICA. REAVALIAÇÃO

DAS EXPERTISES SOLICITADAS, QUE DEVEM TER RELEVÂNCIA TÉCNICA E/OU FINANCEIRA. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio de edital** do Pregão Eletrônico nº 22/2024, do tipo menor preço global, elaborado pelo **DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE**, que tem por objeto a *“prestação de serviços de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco), em locais onde o DAE executou obras, ligações de água e esgoto, manutenção em redes de água e esgoto, bem como demais locais danificados pelo DAE e de demandas futuras, com fornecimento de veículos, equipamentos e insumos necessários para a manutenção das vias urbanas”*.

1.2 Insurgiu-se **JONAS DE OLIVEIRA MELO SILVEIRA** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) requisição de experiência em sinalização horizontal e vertical, serviço não previsto na planilha orçamentária¹; e
- b) previsão de benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte², as quais, em razão do valor estimado do certame (R\$ 5.233.032,18), deveriam estar impedidas de participar, conforme dispõe o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 14.133/21.

¹ 8.8.3 Atestado(s) em nome da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado com comprovação de experiência na execução de serviço compatível, de igual complexidade ou superior, conforme segue:
(...)

h) Sinalização horizontal e vertical: qualitativo;

² 7.20 Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida por este E. Plenário.

1.4 Em seguida, compareceu **MARCELA FURLAN BAGGIO** queixando-se das seguintes disposições editalícias:

- c) imposição de prova de regularidade fiscal perante todos os tributos federais e Dívida Ativa da União³;
- d) indicação de *expertises* (item 8.8.3, “c” e “e”)⁴ que “*representam o mesmo serviço e, portanto, está sendo solicitado em duplicidade*”, sendo que a soma dos quantitativos exigidos (806 m³) corresponde à 85% (oitenta e cinco por cento) do total estimado para sua execução (924 m³), na Planilha Orçamentária⁵; e
- e) requisição de experiência anterior em atividade (sinalização horizontal e vertical)⁶ sem relevância técnica ou valor significativo para o objeto licitado (pavimentação asfáltica).

1.5 Considerando que o procedimento licitatório se encontrava suspenso e que o teor das previsões editalícias impugnadas poderiam, eventualmente, inibir a ampla participação de interessados, foi determinada a

³ 8.7 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista
(...)

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados

⁴ 8.8.3 Atestado(s) em nome da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado com comprovação de experiência na execução de serviço compatível, de igual complexidade ou superior, conforme segue:

(...)

c) Execução de Capa de Concreto Asfáltico com fornecimento de CBUQ: 403m³;

(...)

e) Recomposição de pavimento asfáltico: 403 m³ ou 10.080 m²;

⁵

4		pavimentação	Unid	Quant	Valor unit	Valor total
4.5	70090088	Capa de Concreto Asfáltico CBUQ faixa “D” do DER, espessura + 4,0 cm	m ³	924,00	R2.231,87	2.062.247,88

⁶ 8.8.3 Atestado(s) em nome da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado com comprovação de experiência na execução de serviço compatível, de igual complexidade ou superior, conforme segue:

(...)

h) Sinalização horizontal e vertical: qualitativo;

extensão dos efeitos da liminar a esta Representante, medida igualmente referendada por este Plenário.

1.6 Notificada, a **Representada** asseverou que *“as irregularidades apontadas na representação já foram objeto de impugnação administrativa, a qual foi devidamente analisada e acolhida pela Administração Pública”*.

Desta forma, entendeu que, *“diante do deferimento da impugnação administrativa, as alterações solicitadas foram incorporadas ao edital, restando sanadas as irregularidades apontadas”*.

Outrossim, ressaltou a *“necessidade urgente de recuperação das vias públicas do município que estão com diversos buracos abertos pelas equipes do DAE,”*.

De outro modo, quanto à segunda Representante, defendeu a cláusula relacionada à regularidade fiscal, mormente no que tange à certidão unificada prevista pela Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, *“que reflete todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e a DAU”*.

Acrescentou que *“as exigências de qualificação técnica passaram por uma reavaliação e foram devidamente ajustadas, visando eliminar qualquer sobreposição de requisitos ou imposição de exigências desproporcionais”*.

1.7 O **Ministério Público de Contas** pronunciou-se pela parcial procedência das impugnações, afastando tão-somente a crítica direcionada à prova de regularidade fiscal.

No mais, ponderou que a Autarquia assumiu o compromisso de publicar nova versão editalícia desprovida das máculas apontadas, sendo incontroversa a procedência das questões restantes.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE pretende a *“prestação de serviços de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco), em locais onde o DAE executou obras, ligações de água e esgoto, manutenção em redes de água e esgoto, bem como demais locais danificados pelo DAE e de demandas futuras, com fornecimento de veículos, equipamentos e insumos necessários para a manutenção das vias urbanas”*.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De plano, afasto desse juízo de reprovação a queixa direcionada à imposição de prova de regularidade fiscal perante todos os tributos federais e Dívida Ativa da União.

Sobre a matéria, necessário destacar que o posicionamento desta Corte, que considero prevalecer com as disposições da Nova Lei de Licitações, tem se orientado no sentido de não haver ilegalidade na requisição genérica de prova de regularidade fiscal, nos moldes do que, inclusive, preceitua o artigo 68, inciso III, da Lei nº 14.133/21, cabendo à licitante demonstrar sua regularidade perante os tributos que incidam sobre a sua atividade.

Outrossim, *“a comprovação é requisitada nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 2/10/14 e alterações, por meio da certidão conjunta de débitos relativos a créditos tributários da Receita Federal do Brasil, acabando por assim associar as contribuições previdenciárias, cuja*

regularidade se impõe como pressuposto para viabilizar contratações com o Poder Público, conforme dispõe o art. 195, § 3º, da Constituição Federal”⁷.

2.4 De outro modo, a Lei federal nº 14.133/21 expressamente veda sejam concedidos às microempresas e empresas de pequeno porte os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 para *“item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte”*.

No caso, a própria Autarquia reconheceu que o valor estimado dos itens da licitação ~~7~~ ultrapassam o limite de receita bruta anual permitido para que tais entidades possam usufruir do tratamento diferenciado, propondo-se a adequar o edital à legislação em vigor.

2.5 Por fim, incontroversas as críticas direcionadas à habilitação técnica (alíneas “c”, “e”, “h”), tendo a Autarquia esclarecido que tais cláusulas *“passaram por uma reavaliação e foram devidamente ajustadas, visando eliminar qualquer sobreposição de requisitos ou imposição de exigências desproporcionais”*.

2.6 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Autarquia adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) excluir a possibilidade de concessão de benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte; e
- b) reavaliar as exigências de habilitação técnica, eliminando qualquer sobreposição de requisitos ou imposição de expertises em atividades que não tenham relevância técnica e/ou valor significativo.

⁷ Processo TC- 0024766.989.20-6. Sessão Plenária de 03-02-21. Relator Conselheiro RENATO MARTINS COSTA.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório relacionados.

A Autarquia Municipal deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO